



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Diogo dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 11 de abril de 2017, na Rua André Francisco, 6, por volta das 14h00, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de cocaína e 10 de *crack*.

Determinada a notificação do réu (fls. 194), houve resposta (fls. 227/229) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 232). Em audiência foi colhida a prova oral e o réu interrogado, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 243/244.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A prova dos autos demonstra de forma cabal que o réu praticou os fatos imputados na denúncia, não merecendo acolhida quaisquer pretensões de desqualificar a palavra dos policiais.

De fato, os policiais ouvidos, contra quem não há nada de concreto nos autos, não havendo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão, foram uníssonos ao afirmar que foram apurar denúncia de tráfico no local, onde avistaram o réu em típica movimentação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

deste tipo de comércio, tendo um dos agentes disfarçadamente dele se aproximado e comprado uma porção de droga, quando ele foi detido, e encontrado o restante do entorpecente.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão do réu (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias, além da movimentação visualizada pelos policiais e da própria venda a um deles) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Por fim, a afastar qualquer dúvida, há a integral confissão do réu em juízo, restando a acusação incontroversa.

Tem-se, assim, um conjunto probatório forte e coerente em desfavor do réu, suficiente a gerar a convicção de que realmente ele portava a droga citada na denúncia, e que o fazia para fins de tráfico, sendo de rigor sua condenação.

Assim, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

organismo do usuário. Já o *crack* ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, aumento esta pena e, em se tratando de *crack*, como no presente caso, é de rigor um aumento ainda maior, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Mas, além disso, há que se observar os maus antecedentes do réu, conforme certidão de fls. 214.

Por tudo isso, fixo a base em um quinto acima do piso legal.

Na segunda fase, observo que o réu é duplamente reincidente, uma vez pelo grave crime de roubo (fls. 226 e 213), o que denota personalidade recalcitrante, e recomenda maior rigor na fixação da pena, levando a um aumento de pelo menos um quinto, acima do tradicional sexto, este reservado à hipótese de uma única condenação anterior por crime de outra natureza e menor gravidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Mas ele é também confesso.

Contudo, tem-se que por expressa previsão legal (art. 67 do Código Penal), a reincidência é preponderante. Nesse sentido, a jurisprudência:

PENA - Fixação - Atenuantes - Estelionato - Reincidência - Pretensão de abrandamento da pena, ante a confissão - Descabimento - A reincidência é preponderante sobre a confissão - Precedentes do STF - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 484.465-3/3-00 - Marília - 5ª Câmara Criminal - Relator: Damião Cogan - 28.09.2006 - V.U. Voto n. 9.174)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 1º, DO CP. REPOUSO NOTURNO. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 67 DO CP. PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE.

I - Aplica-se a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade, "pouco importando que tenha sido praticado em dependência não integrante do corpo principal da residência da vítima" (cf. STF/RE - ED nº 117966/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 29/09/89; Precedentes). No caso, foram subtraídas, durante a madrugada, roupas que estavam estendidas no varal da residência da vítima, enquanto ela e sua família dormiam.

II - A circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal. (Precedentes).

III - A pena privativa de liberdade não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras atenuantes. (Súmula n.º 231 - STJ).

Recursos especial provido.

(REsp 920.022/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28.06.2007, DJ 10.09.2007 p. 304)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Manifestamente insuficiente a prova do roubo, é imperativa a desclassificação para o ilícito tipificado no artigo 129, parágrafo 1º, inciso I, do Código Penal.

2. A circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, identificada, na jurisprudência dominante na 3ª Seção, com a confissão voluntária.

3. Ordem concedida.

(HC 43.014/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 19.06.2007, DJ 29.06.2007 p. 723)

HC 71094 / SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK - Julgamento: 29/03/1994 - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA. FIXAÇÃO. Concurso de atenuante e agravante. Preponderancia da reincidencia sobre a confissão espontanea. Ausência de ilegalidade. O tribunal de origem, ao reformar a sentença de primeira instância, elevou a pena acima do minimo legal a vista do que dispõe o artigo 67 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. Habeas corpus indeferido.

Assim, do confronto entre a reincidência e a confissão, é de rigor que decorra o aumento da pena, mas em um patamar mais brando do que o que seria aplicado caso não houvesse a confissão, razão pela qual reduz o aumento, que seria de um quinto, para apenas um oitavo.

E cabe observar que não há qualquer vedação ao reconhecimento tanto dos maus antecedentes como da reincidência, desde que considerados com base em certidões por condenações distintas. São institutos diversos, com requisitos e consequências diferentes, não se confundindo. Uma pessoa pode ser



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

portadora de maus antecedentes, sem ser reincidente. E pode ser reincidente por apenas uma condenação anterior, sem assim caracterizar também maus antecedentes. Não se confundem, portanto, sendo possível a cumulação de tais circunstâncias quando da dosimetria da pena, o que, na verdade, apenas atende o comando constitucional de individualização das penas, não havendo dúvida de que merece uma sanção maior quem é recalcitrante na prática de delitos, e ainda mais severa quem demonstra ter uma vida inteira voltada ao envolvimento com o ilícito. Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 61, I, DO CP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias condenações com trânsito em julgado, podendo umas serem consideradas na primeira fase e outras na segunda.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1067537/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, REPDJe 26/09/2011, DJe 15/08/2011)

Pela mesma reincidência e maus antecedentes, denotando significativa propensão do réu à prática de crimes, não faz ele jus ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

E não há nisso nenhum *bis in idem*, mas tão somente a não satisfação pelo réu dos requisitos, bastante razoáveis, estabelecidos pelo legislador para um benefício que é excepcional, voltado àquela pessoa que tenha tido um envolvimento absolutamente isolado e ocasional com tal prática criminosa, sem maior gravidade, e merecedor de um tratamento diferenciado. E nesse sentido da validade dos requisitos legais para tal benefício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. AGENTE REINCIDENTE E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS EFEITOS PRÓPRIOS DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Constatando-se a ocorrência da reincidência, ausente ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista o não preenchimento de exigência determinada nesta regra, qual seja, ser o agente primário.

2. Não há o que se falar em bis in idem, mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente.

3. Ademais as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do agente, somadas à quantidade e à diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder, levaram à conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, dedicando-se a atividade criminosa.

(...)

(HC 242.769/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 21/09/2012)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica.

4. Ordem denegada.

(HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012)

Assim, finalizo a pena do réu em 6 anos e 9 meses de reclusão, e 675 dias-multa, estes no piso.

Pelas mesmas razões supra mencionadas, o regime inicial é o fechado, sendo descabida a substituição da pena.

E, tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, especialmente observando a pena aplicada e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, que denotam ser pessoa voltada à prática dedelitos, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar solto, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar **Diogo dos Santos**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, observada a progressão diferenciada e a reincidência, e 675 dias-multa, estes no mínimo legal.

O réu **não** poderá apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado**,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03, ressalvada eventual inexigibilidade em caso de pobreza, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, que fica presumida pela atuação da Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, **18 de julho de 2017.**

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
--

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):